

1500921-62.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. Ele levou a mão na cintura para esconder algo e isso gerou suspeitas. Encontrou as drogas com ele e ele confessou tráfico de drogas. Abordou o réu uma vez por envolvimento em roubo de celular. No mesmo sentido, Juvenal Estevão de Macedo - Guarda Municipal. Interrogado, o réu disse que pegou as drogas para comercializar em troca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500921-62.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000763

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170572/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 25729623 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2170572 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TEIXEIRA CARVALHO

Réu Preso

Aos 04 de outubro de 2022, às 15:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. DENIS PEIXOTO PARRON - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUCAS TEIXEIRA CARVALHO - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC FRANCISCO DERNIVAL MIRANDA JÚNIOR - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JUVENAL ESTEVÃO DE MACEDO - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas GC FRANCISCO DERNIVAL MIRANDA JUNIOR e GC JUVENAL ESTEVÃO DE MACEDO.

Após, o réu LUCAS TEIXEIRA CARVALHO foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "LUCAS TEIXEIRA CARVALHO como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Feito regularmente processado. Procede a ação penal. DOS FATOS Consta dos incluídos autos de inquérito policial que, no dia 23 de junho de 2022, por volta de 15h45min, nas dependências da Praça da Pista de Skate do Bairro Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, LUCAS TEIXEIRA CARVALHO, qualificado e indiciado às fls. 04/05 e 23/24, trazia consigo, nas imediações de recintos públicos destinados a atividades sociais, culturais, recreativas e diversões de qualquer natureza, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 243 (duzentas e quarenta e três) pedras de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 22,3g (vinte e dois gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, LUCAS - que ostenta condenação criminal definitiva - trazia consigo as drogas acima descritas para comercialização nas dependências da "Praça da pista de skate da Paulicéia". Em plena atividade espúria, foi surpreendido pela aproximação de guardas municipais em patrulhamento. Nesse instante, escondeu algo na cintura e disfarçadamente tentou se evadir da abordagem. Diante desse comportamento furtivo, LUCAS foi abordado e revistado. Em sua posse os agentes localizaram 243 (duzentas e quarenta e três) pedras de crack e R\$67,00 (sessenta e sete reais) (foto fls. 12/13). Informalmente, confessou a mercancia ilícita. Na delegacia, reafirmou que vendia entorpecentes no local (fls. 04/05). O exame pericial constatou a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição e apreensão fls. 11, foto fls. 12/13 e laudo fls. 15/17). Considerando as circunstâncias da prisão, notadamente a condição pessoal do agente, o local em que reiteradamente são registradas ações policiais de combate ao tráfico de drogas, a considerável apreensão de pedras de crack com embalagens padronizadas, bem como dinheiro em espécie, é certo que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito. DA PROVA JUDICIAL Francisco Dernival Miranda Júnior - Guarda Municipal - disse que viu o réu comportando-se de forma suspeita no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico. Ele levou a mão na cintura para esconder algo e isso gerou suspeitas. Encontrou as drogas com ele e ele confessou tráfico de drogas. Abordou o réu uma vez por envolvimento em roubo de celular. No mesmo sentido, Juvenal Estevão de Macedo - Guarda Municipal. Interrogado, o réu disse que pegou as drogas para comercializar em troca de algumas porções para uso próprio. Estava na abstinência e praticou os fatos. Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011). Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498). E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira,

uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10). DA PENA Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 36/41): LUCAS TEIXEIRA CARVALHO é reincidente - condenado por roubo nos autos n.º 1500789-39.2021.8.26.0599 e em cumprimento de pena (t.j. em 26.11.2021). Pena acima do mínimo legal. Regime fechado. Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos. Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes. O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90). O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014). Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06. DO PEDIDO Ante o exposto, pela procedência da presente ação penal nos termos da inicial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas

Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreram de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado e efetuaram a sua revista pessoal sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível e somente porque estavam “em patrulhamento” no local dos fatos e o réu apresentou “escondeu um objeto na cintura” ao ver a viatura, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuíssem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: “Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado.” (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); “Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus.” (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: “Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações”. E ainda: “Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.”. No mais, corroborando esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, durante julgamento emblemático proferido no REsp nº 1.977.119/SP (2021/0391446-0), definiu exatamente quais são as atribuições da Guarda Municipal na ordem jurídica brasileira, deixando claro que não é função da referida Instituição patrulhar eventuais “pontos de tráfico de drogas”, realizar abordagens e revistas pessoais de indivíduos suspeitos ou investigar denúncias anônimas relacionadas ao comércio de entorpecentes ou outros delitos cuja prática não atinja de maneira evidente e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Além disso, restou expressamente consignado no v. acórdão que o flagrante previsto no artigo 301 do Código de Processo Penal não autoriza a atuação desenfreada da Guarda Municipal e a realização de todo e qualquer tipo de abordagem ou busca pessoal. A norma em questão permite somente a prisão nos casos dos

flagrantes visíveis “de plano”, o que não é o caso de situações em que o delito só se evidencia após atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como busca pessoal ou domiciliar. E, por fim, a r. decisão também observou que, diante da natureza sui generis dos Guardas Municipais, a eles é atribuída, na verdade, a função de coibir os casos de flagrante delito vinculados à sua função específica, qual seja, a tutela dos bens, serviços e instalações do Município, situação na qual o tráfico de drogas, geralmente, não se enquadra. Todavia, se superada a preliminar, QUANTO AO MÉRITO, as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Francisco, GCM, declarou que passavam pelo local, que é uma quadra de skate e possui duas escolas. Costumam fazer o patrulhamento ali porque é um ponto de tráfico e várias pessoas fazem uso de entorpecentes, além de depredarem a quadra. Visualizaram o acusado isolado. Algumas pessoas usavam a quadra. Ao ver a viatura, ele colocou um objeto na cintura, ocultando-o. Por conta disso, efetuaram a abordagem. Na posse do réu, encontraram as drogas descritas na denúncia, além de R\$ 67,00 em dinheiro. O acusado confessou informalmente o tráfico e disse que iniciou a venda por volta das 12 horas, permanecendo até as 18 horas. Já abordou o acusado em virtude de um roubo de celular. A testemunha Juvenal, GCM, declarou que estava patrulhando na pista de skate da pauliceia, que é situada entre duas escolas. Lá o tráfico de entorpecentes é constante, assim como a depredação do patrimônio. Encontraram o réu, que colocou um objeto na cintura. Diante disso, efetuaram a abordagem e localizaram 246 porções de crack, além de R\$ 67,00 em notas trocadas. O acusado confessou informalmente que estava vendendo drogas. Não o conhecia antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que fazia 08 meses que tinha saído da prisão. Uma semana antes dos fatos, brigou com sua namorada e ficou 05 dias usando drogas no centro de Piracicaba. Quando estava retornando para casa, passou pelo local dos fatos e foi abordado por um veículo ônix branco. O motorista ofereceu a venda das drogas, em troca do réu ganhar 05 pedras de crack. Por conta disso, aceitou comercializar o entorpecente. O Guarda já o conhecia, por isso foi abordado e agredido. Está arrependido. Recebeu as drogas para venda. Excelência, em que pese o acusado ter reconhecido a prática dos fatos, sua confissão, como qualquer outra prova, possui valor relativo e deve ser corroborada pelo restante das evidências dos autos, o que não ocorreu neste caso. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Guardas Municipais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança patrimonial do Município ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: “Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente.

Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal – Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 – grifado). [16:44]

Rafael Bresciani Marracini Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFe, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda:

trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in *Direitos Humanos – Visões Contemporâneas*, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, caso não se proceda à absolvição do acusado, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, eis que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese em testilha. Isso porque, para a incidência da majorante em comento, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para determinado mercado consumidor. Assim, a causa de aumento da pena somente tem lugar quando o agente, nos locais ali especificados, encontra-se com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes, presidiários ou pessoas que frequentam um determinado evento, o que não ocorreu nesse caso. Nestes termos, o simples fato de o denunciado ter sido surpreendido próximo a uma escola e a um equipamento de lazer (art. 40, III) não configura, por si só, a incidência da causa de aumento. Entendimento contrário traduzir-se-ia em responsabilização objetiva, vedada em nosso sistema penal. Isso porque a assunção deste tipo de responsabilidade em matéria penal importa lesão a um sem-número de princípios constitucionais, como o princípio da culpabilidade individual, a individualização da pena, a proporcionalidade das reprimendas e, no limite, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Assim, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para aquele mercado consumidor. Desta forma, diante da flagrante impropriedade da prova em demonstrar a configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva. Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito do depoimento dos Guardas, não existiam sequer denúncias prévias apontando o acusado como o responsável pelo tráfico de drogas na região e não foram avistadas condutas prévias que indicassem o envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes (p. ex., recebimento de dinheiro, entrega de objetos, etc.), além de não terem sido apresentados outros indivíduos como possíveis compradores das drogas e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários

outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33,

§ 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminoso), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Requer-se, também, o AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. Excelência, caso não se proceda à absolvição do acusado, de rigor reconhecer-se que o aumento gerado pelo art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 deve ser afastado, eis que a circunstância prevista no referido dispositivo legal não restou devidamente configurada na hipótese em testilha. Isso porque, para a incidência da majorante em comento, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender

substâncias entorpecentes para determinado mercado consumidor. Assim, a causa de aumento da pena somente tem lugar quando o agente, nos locais ali especificados, encontra-se com o intuito de conseguir clientela ou ampliar seu comércio de tóxicos, difundindo o vício entre doentes, estudantes, presidiários ou pessoas que frequentam um determinado evento, o que não ocorreu nesse caso. Nestes termos, o simples fato de o denunciado ter sido surpreendido próximo a uma escola e a um equipamento de lazer (art. 40, III) não configura, por si só, a incidência da causa de aumento. Entendimento contrário traduzir-se-ia em responsabilização objetiva, vedada em nosso sistema penal. Isso porque a assunção deste tipo de responsabilidade em matéria penal importa lesão a um sem-número de princípios constitucionais, como o princípio da culpabilidade individual, a individualização da pena, a proporcionalidade das reprimendas e, no limite, o fundamento da dignidade da pessoa humana. Assim, é de suma importância que se comprove a existência do elemento subjetivo, qual seja, a intenção incontestável de vender substâncias entorpecentes para aquele mercado consumidor. Desta forma, diante da flagrante impropriedade da prova em demonstrar a configuração da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, ela deve ser afastada. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

LUCAS TEIXEIRA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de junho de 2022, por volta de 15h45min, nas dependências da Praça da Pista de Skate do Bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, nas imediações de recintos públicos destinados a atividades sociais, culturais, recreativas e diversões de qualquer natureza, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 243 (duzentas e quarenta e três) pedras de crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 22,3g (vinte e dois gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que LUCAS - que ostenta condenação criminal definitiva - trazia consigo as drogas acima descritas para a comercialização nas dependências da "Praça da pista de skate da Pauliceia". Em plena atividade espúria, foi surpreendido pela aproximação de guardas municipais em patrulhamento. Nesse instante, escondeu algo na cintura e disfarçadamente tentou se evadir da abordagem. Diante do comportamento furtivo, LUCAS foi abordado e revistado. Em sua posse, os agentes localizaram 243 (duzentas e quarenta e três) pedras de crack e R\$ 67,00 (sessenta e sete reais). Informalmente, confessou a mercancia ilícita. Na delegacia, reafirmou que vendia entorpecentes no local. O exame pericial constatou a presença de cocaína nas

substâncias apreendidas.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 89) e apresentou defesa preliminar (fls. 93/97). Após, a denúncia foi recebida (fls. 98/100).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e, em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelas fotografias de fls. 12 e 13 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 74/76, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu confessou a prática do delito. Disse que era dependente químico e estava passando pelo Bairro da Pauliceia, quando encontrou um desconhecido que lhe ofereceu quatro porções de crack para que ficasse no local vendendo entorpecentes. Afirmou que iniciou as vendas por volta do meio-dia e foi abordado pelos guardas enquanto traficava. Disse que não sabia informar as características do proprietário das drogas (fls. 04/05). Em juízo, ratificou sua confissão. Afirmou que fazia oito meses que tinha saído da cadeia e tinha brigado com sua namorada. Alegou que teve uma recaída e ficou cinco dias usando drogas. No dia dos fatos, passou pelo local descrito na denúncia e foi parado por um indivíduo que apresentou uma sacola com drogas e um pouco de dinheiro. Disse que ele lhe ofereceu cinco pedras de "crack" para vender o entorpecente.

E a confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova.

O guarda civil Francisco relatou que passavam pelo local, uma quadra de skate ao lado de duas escolas, bastante conhecido como ponto de tráfico e também de uso de drogas, sendo frequentes os casos de depredação das escolas. Disse que o réu estava isolado e, quando viu a viatura, colocou algo na cintura e saiu andando, olhando para trás. Então, suspeitando que ele estava portando algo ilícito, fizeram a abordagem e encontraram, nas vestes íntimas, 243 porções de crack e R\$ 67,00. Indagado, o réu confessou que estava no local para comercializar droga, tendo começado às 12h, bem como que o turno dele seria até as 18h.

No mesmo sentido as declarações do guarda civil Juvenal.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Por fim, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

Confira-se, sobre o tema, o seguinte julgado: "Habeas Corpus – Tráfico de drogas- Pleito de revogação da prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão realizada por Guardas Municipais. Atuação dos Guardas Municipais. Ausente ilegalidade – Artigo 301 do CPP – Qualquer pessoa do povo pode, e as Autoridades policiais e seus agentes devem realizar prisões em flagrante – Crime de Tráfico de Drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento. Jurisprudência do C. STJ. No caso em tela, ao que consta, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. No mais, eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente. Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2014342-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não bastasse essa orientação já consolidada na jurisprudência, há que se ressaltar que, conquanto não seja essa essencialmente sua função, o guarda municipal está autorizado por norma legal expressa a encaminhar à presença da autoridade policial indivíduos presos em flagrante delito, consoante a regra inscrita no artigo 5º, inciso XIV, da Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais).

Enfim, tendo os guardas terem apreendido entorpecentes em poder do réu, que admitiu sua posse, resta certa a autoria.

E a quantidade de entorpecente apreendida, aliada à forma como estava acondicionado, ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, e à confissão do acusado, deixam evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 00038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, valendo anotar que, para sua caracterização, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma

pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Por fim, ficou devidamente caracterizada a causa de aumento descrita no art. 40, III, do referido diploma legal, eis que o crime foi praticado nas dependências de uma praça pública, onde, aliás, funciona uma pista de skate.

Não é demais anotar que, para a incidência da majorante, não é necessário que o agente vise a difusão do entorpecente entre frequentadores da área de lazer, bastando que o delito se pratique no local, porque o objetivo da lei é impedir, no máximo, a propagação da toxicomania em locais de maior concentração popular.

Nesse sentido, já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça quando do julgamento da Apelação nº 0320753-56.2010.8.26.0000, de que foi Relator o E. Desembargador JUVENAL DUARTE: "E não há como desconsiderar que a causa de aumento em exame é de natureza objetiva, irrelevante, portanto, para a sua configuração, indagar se o autor do crime visava comercializar ou fornecer drogas aos frequentadores desses estabelecimentos públicos, pois a lei exige tão somente que o tráfico ocorra nas imediações desses locais, porquanto, é inegável, o fluxo e a concentração de pessoas nesses sítios facilitam a ação de traficantes e a prática ilícita, dificultando a ação policial, evidenciando que o dano à saúde pública se potencializa exponencialmente".

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal